

刑 法
No100

予備独自問題 H27-3

(配点：2)

月	日
月	日

緊急避難に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 国家的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為については、緊急避難が成立することはない。

イ. 現在の危難の発生原因は人の行為に限られず、自然災害や動物による危害も含まれる。

ウ. 「やむを得ずにした行為」とは、その避難行為をする以外には現在の危難を避けるための他の方法がなく、その避難行為に出たことが条理上肯定できる場合をいう。

エ. 現在の危難を避けるためにした行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えた場合、当該行為をした者の刑を免除することはできない。

オ. 緊急避難が違法性阻却事由であると考えた場合、緊急避難と認められる行為に対して正当防衛が成立することはない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No100	緊急避難	正答率 64%
予備H27-3	正解 2	

ア 誤っている

37条1項本文。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。国家的法益が、ここにいう「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産」(37条1項本文)に含まれるかについて、同文言は例示的列举と解されていること、緊急避難の適用を除外する理由もないことから、保全法益としては、国家的法益をも含むと解されている。よって、国家的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為にも、緊急避難が成立する余地はある。

イ 正しい

正当防衛における「不正の侵害」が、人の違法な行為でなければならないかについて議論があるのに対し、緊急避難(37条1項本文)における「危難」は、その発生原因に制限はなく、人の行為、自然現象、動物、疾病、飢餓などあらゆるものを含むとされている。判例も、豪雨で自己の耕作する水田が湛水し、田植えをしたばかりの稲苗が増水のため水没して枯死するおそれがあったため、排水を妨げていた水利組合の管理する川の板堰を損壊したという事案において、「現在の危難」(37条1項本文)に自然災害が含まれるとしている(大判昭8.11.30)。よって、危難の発生原因には自然災害や動物による危害も含まれる。

ウ 正しい

最大判昭24.5.18。判例は、「『已ムコトヲ得ザルニ出デタル』というのは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する」としている。

エ 誤っている

37条1項ただし書。自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減輕し、又は免除することができる。よって、現在の危難を避けるためにした行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えた場合には、37条1項ただし書に当たり、刑を減輕するにとどまらず、免除することもできる。

オ 正しい

正当防衛が成立するためには、急迫「不正」(36条1項)の侵害に対するものであることが必要である。よって、もともと違法でない行為に対してはもちろん、違法性が阻却される行為に対しても正当防衛は成立しない。本記述のように、緊急避難が違法性阻却事由であると考えた場合、緊急避難と認められる行為は違法性が阻却されるから、「不正」の侵害には当たらない。よって、かかる行為に対して正当防衛が成立することはない。